

1501247-05.2022.8.26.0540

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIGI MONTEIRO SESTARI

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... e uma carta com anotações relativas ao tráfico, bem como 07 porções de maconha e outras 07 de crack, embaladas para pronta entrega a terceiros. Tráfico de drogas consumado - Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas. Local dos fatos situado em proximidade de uma igreja - Bem reconhecida a causa de aumento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501247-05.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501247-05.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2177408/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 25871662 - CPJ SANTO ANDRE, CZ1585-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2177408 - CPJ SANTO ANDRE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JÚLIO CÉSAR CALADO DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIGI MONTEIRO SESTARI

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu presentante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia JULIO CESAR CALADO DO NASCIMENTO, como incurso na prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Consta da denúncia que:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 30 de junho de 2022, por volta de 17h15min, na rua São Sebastião, altura do n.º.: 13, Vila Linda, nesta cidade, JULIO CESAR CALADO DO NASCIMENTO, qualificado a fls. 09 e "fotografia" a fls. 18, mantinha em depósito, transportava, trazia consigo, guardava, para consumo de terceiros, 162 invólucros plásticos contendo 262,4g (duzentos e sessenta e dois

gramas e quatro decigramas) de "MACONHA", 174 invólucros plásticos, contendo 234,9g (duzentos e trinta e quatro gramas e nove decigramas) de "COCAÍNA" e 610 invólucros plásticos encerrando porção de material sólido petrificado, contendo 280,6g (duzentos e oitenta gramas e seis decigramas) também de cocaína, na forma de pedras de "CRACK", drogas estas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na ocasião, agentes da lei efetuavam patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, e visualizaram o implicado parado defronte a um imóvel aparentemente abandonado na posse de uma bolsa nas mãos dele. Logo que o indiciado notou a aproximação dos agentes da lei ele fugiu correndo a pé e dispensou durante a fuga a bolsa que ele trazia nas mãos, mas foi perseguido e detido em seguida pelos agentes da lei. A bolsa dispensada pelo suspeito foi imediatamente apreendida e em seu interior foram encontradas partes das aludidas drogas, sendo 69 porções de "crack", 18 porções de "maconha" e 54 porções de "cocaína", sendo certo que no imóvel em que o implicado estava parado em frente, os agentes da lei apreenderam os demais entorpecentes, sendo 541 porções de "crack", 144 porções de "maconha" e 120 porções de "cocaína".

Determinada a notificação do acusado para oferecer defesa prévia e designada audiência de instrução (fls. 73/75).

Em audiência de fls. 122/126 a Defensoria apresentou a defesa preliminar, tendo havido recebimento da denúncia em audiência em 28/07/2022 e realizada a citação do acusado, colhido o depoimento de duas testemunhas guardas civis e realizado o interrogatório do acusado. A defesa requereu a oitiva das testemunhas Yasmin e Gisele como testemunhas do juízo, havendo deferimento e designando-se nova audiência em continuação.

A defesa em petição de fls. 127 pleiteou a substituição da testemunha Yasmin pela testemunha Bianca e acréscimo de Natanel, perfazendo-se três testemunhas a serem ouvidas: Gisele Souza Alvez das Neves, Bianca Vitória da Silva e Natanael Gomes da Silva Junior.

Em audiência em continuação foram ouvidas as testemunhas e encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público pediu a procedência da denúncia nos exatos termos em que formulada com a fixação de regime fechado. A Defesa, por sua vez, requereu preliminarmente a nulidade da abordagem do flagrante e, no mérito, a aplicação do tráfico privilegiado e os benefícios penais cabíveis.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Preliminarmente, não há se falar em nulidade do processo por ilegalidade do flagrante ter sido levado à cabo por guardas municipais.

No âmbito constitucional, interpretando-se o disposto no art. 144, § 8º da Carta Magna o C. Supremo Tribunal Federal, já assentou que "As Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF)", conforme se extrai do acórdão proferido no RE 846854, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, PUBLIC 07-02-2018.

Tratou-se de uma interpretação amparada tanto no princípio da unidade da Constituição, já que esta deve ser interpretada como um texto uno e indivisível (e não em pedaços de artigos), quanto na máxima efetividade das normas constitucionais, ou seja, o intérprete deve conferir uma interpretação que dê a maior eficácia aos direitos fundamentais, como é o direito à segurança (art. 5º, caput, da CF).

A isso se assemelha o brilhante ensinamento de EROS ROBERTO GRAU, ao ponderar que "não se interpreta o direito em tiras, aos pedaços" (Por que tenho medo dos juizes: (a interpretação/aplicação do direito e os princípios). 10ª ed. São Paulo: Malheiros, 2021, pág 86).

Ou seja, a disposição topográfica da inclusão das Guardas Municipais no CAPÍTULO III - DA SEGURANÇA PÚBLICA, no preciso art. 144 da Constituição Federal não foi

meramente acidental e a dicção do seu § 8º ao possibilitar que os Municípios constituam as Guardas Municipais para proteção “de seus bens, serviços e instalações” não a exclui de uma atuação preponderante na segurança pública “essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF)”, conforme os demais órgãos elencados nos incisos I a VI do caput do art. 144. Não se está dizendo aqui que se atribui, por via interpretativa, a competência às Guardas Municipais para a realização de policiamento ostensivo, competência esta exclusiva das polícias militares, na forma do § 5º do art. 144 da Constituição Federal, mas que elas de fato integram e executam atividades de segurança pública, conceito mais amplo que se define pela reserva legal do §7º do art. 144 da Constituição Federal, norma de eficácia limitada que foi regulamentada pela Lei Federal nº 13.675/2018.

Outrossim, os fatos já se deram sob a égide da Lei Federal nº 13.022/2014 - Estatuto Geral das Guardas Municipais - que positivou o entendimento de que, além da segurança patrimonial, estabelecida no art. 144 da Constituição Federal, as guardas municipais podem atuar de forma preventiva e integrada aos demais órgãos da polícia administrativa e de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, bem como “atuar, preventivamente e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais” (art. 5º, III).

Este julgador não se olvida que está pendente de julgamento o RE 608.588 (REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 656) em que se discute, “à luz do art. 144, § 8º, da Constituição federal, o limite da atuação legislativa dos municípios para fixar as atribuições de suas guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do município.”

No entanto, pelos fundamentos acima descritos e o princípio da presunção de constitucionalidade das leis deve se dar prevalência à competência não exaustiva dos Municípios para proteção de sua população, amparado no precedente já citado que lhe confere típica atuação na segurança pública.

De mais a mais, foi editada também a Lei Federal nº 13.675/2018 que disciplinou a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do §7º do art. 144 da Constituição Federal, assentando no seu art. 9º, caput o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), integrado pelos órgãos do art. 144 da Constituição Federal e as guardas municipais como integrantes operacionais do SUSP (art. 9º, § 2º, VII), com a finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 1º)

Por fim, é de se lembrar que os guardas civis municipais, como quaisquer do povo, podem efetuar a prisão de quem estiver em flagrante, de acordo com o CPP, art. 301, como ocorreu no caso concreto, já que o réu estava na posse de uma bolsa que posteriormente foi verificada contendo drogas.

É o entendimento também deste E. Tribunal de Justiça:

Habeas corpus – Tráfico de drogas – Revista pessoal e flagrante realizado por guardas municipais – Crime permanente – Possibilidade – Exegese do art. 301, do Código de Processo Penal – Precedentes – Art. 144, § 8º, da Constituição Federal regulamentado pela Lei nº 13.022/2014 e Lei nº 13.675/18 – Nulidade – Inocorrência – Trancamento da ação penal – Impossibilidade; Habeas corpus – Prisão em flagrante – Conversão em preventiva – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Decisão bem fundamentada – Expressiva quantidade de drogas apreendidas – Paciente que possui maus antecedentes e responde a outro processo suspenso, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Constrangimento ilegal – Não caracterização – Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2106210-75.2022.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda – 15ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/06/2022; Data de Registro: 13/06/2022) Igualmente, não há se falar em ilegalidade da prisão em flagrante por falta de justa causa para a abordagem e a realização da busca pessoal.

A busca pessoal foi realizada de forma legal preconizada pelo art. 244 do CPP, havendo fundada suspeita, não havendo que se falar em nulidade posterior deste procedimento.

A atitude suspeita se deu no momento exato em que o próprio réu tentou empreender fuga quando avistou os guardas municipais, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, ato incompatível com um cidadão comum que não possui receio da força pública.

Conforme os ensinamentos de FERNANDO DE ALMEIDA PEDROSO:

“A própria fuga do agente de crime, ao perceber a aproximação de policiais ou circunstâncias, indica envolvimento no fato delituoso, pois denota conduta incompatível com aquela que teria pessoa que trouxesse consciência incontaminada, serena e tranquila” (Prova penal. Doutrina e Jurisprudência. 2ª ed. rev. at. e ampl., ed. RT, p. 96). (grifos meus)

Assim, houve efetivamente o flagrante e a busca pessoal não foi ilegal, já que demonstrada a fundada suspeita pelos guardas civis quando da abordagem de JULIO CESAR, arrimadas em elementos concretos acima delineados, respeitando-se os ditames do art. 244 do CPP.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

Tráfico de drogas, roubo e receptação. 110,66g de cocaína, 11,82g de crack, 75,2g de maconha. 1. Nulidade da busca pessoal. Inocorrência. Observância aos termos do artigo 244 do CPP. Existência de fundada suspeita para realização da busca. Policiais militares em policiamento ostensivo, visualizaram os réus em conhecido ponto de tráfico, momento que ambos empreenderem fuga ao verem a viatura. Elementos concretos para despertar fundada suspeita nos agentes públicos, os quais estavam autorizados a realizar busca pessoal nos réus, o que ocorreu de forma regular. 2. Roubo. Mantida absolvição decretada em primeiro grau. Fragilidade de provas. Reconhecimento fotográfico feito em sede policial, que não recebeu a devida confirmação por ocasião do reconhecimento pessoal feito em juízo. 3. Receptação. Decretada a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Objeto do crime, aparelho celular. Ainda que a versão apresentada pelo réu Douglas seja duvidosa, nada foi produzido nos autos o sentido de abalá-la. A despeito da origem ilícita, o bem adquirido pelo réu é um telefone celular, produto de rápida depreciação de seu preço, razão pela qual não há que se exigir que o adquirente tenha especial cautela quando compra tal produto fora de estabelecimentos comerciais especializados nesse tipo de aparelho. Acrescente-se que a aquisição de bens móveis via mercado on line é conduta frequente e que não impõe aos usuários maior cuidado. Outrossim, o valor declarado pelo réu como aquele pago pelo produto, qual seja, R\$ 400,00 (quatrocentos reais) não pode ser considerado irrisório. 4. Tráfico. Conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Provado o intuito de mercancia. Impossibilidade de desclassificação. 5. Aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei n. 11343/06 em sua fração máxima em razão da quantidade da droga apreendida. 6. Fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", tendo em vista a quantidade de pena fixada, primariedade dos réus e o tempo de prisão cautelar. 7. Substituída a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e na prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo. Recurso do Ministério Público não provido. Recurso dos réus parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0001889-56.2016.8.26.0542; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro: 07/03/2019)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRELIMINARES. Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva - Ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares. Inocorrência. Abordagem que não foi aleatória, mas sim calcada em elementos concretos. Fundada suspeita caracterizada. Inteligência do artigo 244 do CPP. Precedente do STJ - Nulidade por cerceamento de defesa. Pleito de instauração de incidente de dependência químico-toxicológica. Inocorrência - Rejeição. MÉRITO - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Versão do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (52 pedras de crack, com peso de 16,16 gramas), além de celular - Desclassificação para uso próprio. Impossibilidade - Condenação mantida. PENAS e REGIME DE

CUMPRIMENTO - Bases nos patamares - Múltipla reincidência específica (1/3) - Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Regime inicial fechado - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e II) - Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1501484-95.2020.8.26.0544; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vinhedo - 2ª Vara; Data do Julgamento: 12/04/2021; Data de Registro: 12/04/2021)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Inexistem direitos absolutos e ilimitados e, para que aparentes contradições entre princípios de igual matiz sejam solvidas - aplicando-se a norma constitucional de forma segura e coerente -, utiliza-se o princípio também constitucional da proporcionalidade. (...) 4. Em razão do alto grau de afetação de direitos e por ser vexatória e invasiva, a medida de busca pessoal é excepcional, devendo a autoridade policial agir com extrema cautela, evitando-se atos abusivos, somente levando-a a cabo quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida, com objetos que constituam corpo de delito, com instrumento de crimes, entre outros. Não se pode dizer que os réus foram aleatoriamente escolhidos para a revista, sendo o procedimento adequado. (...) 8. Habeas corpus não conhecido. (STJ HC nº 257.002/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, J. 17.12.2013, DJe 19.12.2013)

Superada as preliminares, o feito encontra-se em ordem.

Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

A materialidade delitiva resultou provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4) boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação provisório (fls. 17/20), laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 111/113), bem como pela prova oral colhida.

Por sua vez, a autoria é certa e as provas dos autos demonstram que ela recai, com efeito, sobre o acusado. O conjunto probatório é seguro e autoriza a condenação.

A testemunha ANDRÉ DA SILVA LUPECINO, em juízo, relatou ser guarda civil municipal e que no dia dos fatos estava em patrulhamento, sendo o local conhecido pela mercancia de drogas entorpecentes de difícil acesso com viatura de quatro rodas, indo a pé com o seu companheiro de farda em uma das vielas, saindo numa espécie de bolsão quando avistaram o réu com uma pequena bolsa na mão e que ao perceber a presença deles largou-a e saiu correndo em direção à um bar, sendo abordado neste bar onde foi feita uma busca pessoal. Conduzido até o local onde estava parado em frente à uma casa velha destruída, existindo vestígios de embalagens vistoriaram e encontraram a outra quantidade de entorpecentes. Afirmou que não perderam o réu de vista, sendo o mesmo que visualizaram com a bolsa, não o conhecendo anteriormente. Afirmou que quando visualizou o réu ele estava sozinho e não havia mais ninguém. Não verificaram de quem era o imóvel, pois estava abandonado. Não foram encontrados valores com o réu. Que o réu reside em outro município. Que a incursão foi a pé. Que o patrulhamento era preventivo.

Em Juízo a testemunha ANDERSON DIAS DE FIQUEIREDO, relatou que o local da abordagem é um local conhecido pelo tráfico e a guarda estava fazendo patrulhamento de rotina, ingressaram em uma viela e viram o réu que jogou a bolsa e saiu correndo em direção à um bar, recolhida a bolsa estava com entorpecentes, retornando ao local onde o réu estava, uma casa velha, abandonada, encontraram o restante da droga. Que não perderam o réu de vista e que é a mesma pessoa que viram com a bolsa, com absoluta certeza. Que ao final da viela há uma praça, lotada de usuários. Não existiam outras pessoas no local onde ele foi visto. Que no momento que abordaram o réu ele já havia descartado a bolsa que foi recolhida por Lupecino. Que já havia abordado o réu anteriormente. Não sendo nesta abordagem não foi encontrado nada com o réu.

A testemunha de defesa GISELE SOUZA ALVEZ DAS NEVES disse ser ex-cunhada do réu, que era "muito amiga" dele, considerava-o mais do que sua própria irmã. Que soube

da prisão dele. Ele a estava esperando, iria buscar as crianças na escola e tinha acabado de parar de entregar a última marmita para buscar o filho na escola. Ele estava em um bar onde ele entrega as marmitas. Quando desceu os policiais já estavam com ele falando "que era ele" que estava com as drogas. Alega que não era ele quem estava com as drogas, passou o dia inteiro com ele. A data, acredita, era no mês de julho, uma quinta-feira, umas 16h00. Alega que ele não faz "mais coisa errada", já foi preso por tráfico e roubo.

A testemunha de defesa BIANCA VITÓRIA DA SILVA disse ser amiga do réu Júlio. Estava no restaurante/bar de propriedade de YASMIN conversando e ele esperando a ex-cunhada chegar para buscar as crianças, tinha feito sua última entrega de marmitex. Os policiais já entraram no bar e fizeram a abordagem no réu. Recorda-se que um outro menino foi também abordado. Ocorrência se deu no dia 30 do mês de junho, umas 16h00, 16h30. Os policiais apareceram repentinamente e puxaram o réu para fora do estabelecimento.

Em interrogatório perante este Juízo, o réu JULIO CESAR negou os fatos e disse que no dia dos fatos pegou seu filho e o levou na escola, fez a entrega para o restaurante e retornou às 17hrs, momento em que estava esperando sua ex-cunhada Gisele descer do bar. Mandou uma mensagem para ela no Whatsapp dizendo que já a estava esperando. Estava também com uma amiga sua e crianças pequenas, momento em que um suposto olheiro que estava em frente à viela veio correndo na direção do bar e o policial veio correndo bem perto dele, correndo em sua frente, outro policial correndo atrás, o policial que entrou junto com ele o segurou pela blusa, no cangote, no pescoço e o puxou para fora. Esse policial olhou para a sua cara e falou "você também, vem pra fora", momento em que alega ter sido preso e algemado. Depois os policiais ainda começaram a andar no meio da favela da comunidade e encontraram mais drogas lá para cima, bem longe de si.

Ressalte-se, por primeiro, que os guardas civis não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria. E o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

"Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ AC Rel. Synésio de Aquino RDTJR 7/287).

"Não faz sentido repudiar testemunho por provir de agente da polícia. Ao contrário, sua palavra deve ser avaliada e aceita a partir de sua função social que, por isto mesmo, se impõe com o peso mais contundente do que o cidadão comum" (in

"Jurisprudência Penal e Processual Penal", AZEVEDO FRANCESCHINI, vol. 8, pág. 386). No caso, o réu possuía diversas quantidades de droga em sua posse, notadamente 69 porções de "crack", 18 porções de "maconha" e 54 porções de "cocaína" em uma bolsa que ele dispensou ao se deparar com os guardas civis, conforme testemunho de ANDRE e ANDERSON, o que sem sombra de dúvida comprova os entorpecentes serviam à mercancia, já que estavam acondicionados e separados prontos para venda.

É a jurisprudência pacífica deste E. TJSP:

Tráfico de entorpecente. Acusado flagrado em conhecido ponto de mercancia espúria em poder de 53 porções de cocaína, pesando 38,7 gramas, 20 porções de maconha, com peso de 43,9 gramas, e 20 pedras de crack, pesando 4,3 gramas, além da quantia de R\$ 122,00. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares.

Confissão do acusado. Diversidade de drogas que confirmam a posse para fins

mercantis. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Redutor aplicado à fração máxima. Imposição de regime aberto. Cabível substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Parcial provimento ao apelo defensivo. (TJSP; Apelação Criminal 0001132-63.2018.8.26.0616; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Suzano - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/02/2021; Data de Registro: 05/02/2021)

Apelação criminal - Tráfico de drogas - Sentença condenatória pelo art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a desclassificação para o crime previsto no art. 28, da referida lei e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea Tráfico de drogas - Materialidade e autoria comprovadas - Prisão em flagrante - Réu que negou a prática delitiva - negativa que não prospera - Policiais Militares responsáveis pela ocorrência que esclareceram as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, que é a certeza visual do crime, bem como da apreensão das drogas (1,6 g de cocaína e 13,10 g de maconha). Relataram, em suma, que em patrulhamento pelo local dos fatos a fim de apurar uma denúncia, visualizaram o réu, o qual, diante da viatura, tentou fugir para o interior de sua residência, sendo detido. No interior da residência, os Policiais encontraram um bloco e uma carta com anotações relativas ao tráfico, bem como 07 porções de maconha e outras 07 de crack, embaladas para pronta entrega a terceiros. Tráfico de drogas consumado - Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas. Local dos fatos situado em proximidade de uma igreja - Bem reconhecida a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas. Dosimetria - Pena-base exasperada em razão dos maus antecedentes. Nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, o alto poder viciante de uma delas (crack) poderia ensejar maior exasperação. Fração de exasperação mantida, eis que não há recurso Ministerial - Na segunda fase, exasperação decorrente da circunstância agravante da reincidência (específica) - Fração que fica mantida ante o conformismo Ministerial neste ponto. Não cabimento de reconhecimento da confissão espontânea, eis que o réu negou a prática do crime, tanto em Delegacia como em Juízo. Na terceira fase, não cabimento do redutor de pena - réu reincidente específico, o que por si só veda o benefício, como também se dedicava às atividades criminosas, fator que obsta a concessão pleiteada. Na terceira fase, ainda, exasperação decorrente do art. 40-III, da Lei de Drogas. Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado. Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de amparo legal. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0012113-35.2015.8.26.0624; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/10/2019; Data de Registro: 18/10/2019)

No entanto, não pode ser imputado ao réu a posse das drogas encontradas no imóvel abandonado, especificamente 541 porções de "crack", 144 porções de "maconha" e 120 porções de "cocaína", já que as provas são frágeis em afirmar qualquer vínculo de JULIO CESAR com aquele local, havendo mera presunção dos guardas civis de que ele guardava as drogas naquele local.

Não obstante, isolada a tese defensiva do réu e de suas testemunhas defensivas GISELE e BIANCA de que aquele apenas estava em um restaurante em que entregava marmite, subitamente um "olheiro" surgiu, foi apreendido pelos guardas, solto e somente ele, JULIO CESAR, aleatoriamente foi escolhido para ser preso em flagrante por guardas civis que sequer o conheciam.

Suas alegações em interrogatório não são corroboradas por provas produzidas nos autos, apenas dois testemunhos de pessoas extremamente próximas dele que devem ser analisados com cautela por este Juízo.

A um, o réu disse que estava no restaurante de YASMIN e essa pessoa não prestou depoimento em juízo, sendo mera alegação sem comprovação.

A dois, o réu alega que mandou uma mensagem de whatsapp para sua ex-cunhada Gisele dizendo que a estava esperando, prova que facilmente poderia ter sido juntado pela Defesa como elemento que corroborasse sua versão, no entanto, não o fez.

Por fim, o testemunho de GISELE deve ser sopesado com reservas, diante da proximidade e do intuito de livrá-lo da aplicação da lei penal, posto que afirmou em juízo ser "muito amiga" do réu, considerava-o mais do que sua própria irmã, ou seja, praticamente um membro da família.

Assim sendo, estão devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do fato que sobre ele recai, não se sustentando a tese defensiva de negativa de autoria e fragilidade probatória.

No tocante à tipicidade, é assente na doutrina e na jurisprudência que para a caracterização do crime de tráfico de drogas não é necessário que haja provas da comercialização, ou que o réu venha, de fato, a vender entorpecentes, bastando que pratique quaisquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista tratar-se de tipo misto alternativo, de ação múltipla ou de conteúdo variado, que traz dezoito verbos distintos, sendo certo que, no presente caso, os acusados incorreram na prática do núcleo do tipo "trazer consigo" e "transportar". Nesse sentido, a jurisprudência do E. TJSP:

Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Impossibilidade. Quantidade da droga e forma de acondicionamento que evidenciam a prática da traficância. Reconhecimento do delito em sua modalidade tentada. Não cabimento. O tráfico de drogas é tipo penal misto alternativo. Possuindo 18 ações distintas, o delito se consuma com a prática de um dos núcleos do tipo penal. A conduta "trazer consigo" é delito de mera conduta, que não admite a modalidade tentada. Aplicação do redutor do §4º do artigo 33, da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima. Quantidade de droga apreendida que não pode ser considerada expressiva tendo em vista o local de cometimento do delito - a cidade de São Paulo. Fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em face da quantidade de pena aplicada e da primariedade do agente. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0001899-83.2014.8.26.0635; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/12/2015; Data de Registro: 04/12/2015)

APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS PROVA SUFICIÊNCIA Autoria e materialidade suficientemente comprovadas Réu preso em flagrante na posse de expressiva quantidade de entorpecentes (50 invólucros de "crack") Confissão informal ratificada em Juízo Depoimentos seguros e coesos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante Validade de tais testigos que não pode ser elidida pela simples alegação genérica de parcialidade Prescindibilidade de flagrância da comercialização Tipo Penal misto alternativo Crime caracterizado pelo simples fato de o réu trazer consigo estupefacientes para fins de tráfico Suficientes elementos probatórios Sentença integralmente mantida RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0002555-32.2012.8.26.0434; Relator (a): Amado de Faria; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pedregulho - Vara Única; Data do Julgamento: 15/10/2013; Data de Registro: 16/10/2013)

Desse modo, a conduta do réu se subsume perfeitamente ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Descabe, no entanto, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que não preenchidos todos os requisitos para tanto, visto que o acusado ostenta maus antecedentes pelo delito de tráfico de drogas e roubo qualificado tentado e reincidência pelo delito de furto qualificado (fls. 28/30).

Destarte, não faz jus ao benefício legal, aplicado unicamente aos chamados "traficantes de primeira viagem".

Por fim, o acusado era imputável na data dos fatos, tinha consciência do caráter ilícito de sua conduta, e não há quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

Passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e de forma individualizada.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais de que trata o art. 59 do



Código Penal e atento às circunstâncias preponderantes elencadas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que, o acusado ostenta maus antecedentes pelo delito de tráfico de drogas e roubo qualificado tentado e reincidência pelo delito de furto qualificado (fls. 28/30), motivo pelo qual o delito de furto qualificado será utilizado na segunda fase como reincidência, a fim de se evitar bis in idem (Súmula 241 do STJ), porém os demais delitos serão utilizados como maus-antecedentes, ante o sistema da perpetuidade adotado pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário Nº 593.818/SC com repercussão geral (TEMA 150). Igualmente, a Edição nº 26, Item 12, da Jurisprudência em Teses do STJ – “12) Havendo diversas condenações anteriores com trânsito em julgado, não há bis in idem se uma for considerada como maus antecedentes e a outra como reincidência.” (STJ, HC 268659/RS, Julgado em 08/04/2014, HC 241571/MS, Julgado em 11/03/2014, HC 220027/SP, Julgado em 24/10/2013, HC 267543/SP, Julgado em 21/05/2013, HC 173805/SP, Julgado em 19/03/2013, HC 203898/MS, Julgado em 12/04/2012, HC 018549/SP, Julgado em 18/12/2001). Na análise do vetor circunstâncias, previsto no art. 59 do Código Penal, deve ser apreciado o disposto no art. 42 da Lei de Drogas: Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na espécie, apesar de terem sido apreendidas grandes quantidades de droga, não houve prova contundente de que todas pertenciam ao réu, especificamente a maior parte que se encontrava em um imóvel abandonado (541 porções de “crack”, 144 porções de “maconha” e 120 porções de “cocaína”). Portanto, apenas deve ser imputado ao réu as drogas que foram encontradas na sacola dispensada quando ele avistou os guardas civis, notadamente 69 porções de “crack”, 18 porções de “maconha” e 54 porções de “cocaína”, quantidade esta que, apesar da diversidade, não possibilita exasperação da pena base, consoante jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça em caso semelhantes ((Apelação Criminal nº 0001132-63.2018.8.26.061, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. GUILHERME DE SOUZA NUCCI, julgado em 05/02/2021). Sopesadas tais circunstâncias, em razão da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Na segunda fase, há agravante da reincidência pelo delito de furto qualificado, e não há circunstâncias atenuantes, de modo que agravo a pena intermediária e fixo-a em 7 (sete) anos 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento a serem valoradas, de modo que fixo a pena final em 7 (sete) anos 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Considerando a ausência de informações precisas acerca da situação econômica dos réus, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (art. 49, § 1º, do Código Penal e 43 da Lei 11.343/2006).

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§2º e 3º do Código Penal).

Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, incluindo-se aí o tráfico de drogas, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto no art. 33, c/c o art. 59, ambos do Código Penal e nas Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719/STF.

Vide para tanto a ementa:

Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei nº 11.464/07. Pena inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3º, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de

liberdade. Ordem concedida. 1. Verifica-se que o delito foi praticado em 10/10/09, já na vigência da Lei nº 11.464/07, a qual instituiu a obrigatoriedade da imposição do regime inicialmente fechado aos crimes hediondos e assemelhados. 2. Se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena, é natural que ela exista. Do mesmo modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. 3. Na situação em análise, em que o paciente, condenado a cumprir pena de seis (6) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2º, alínea b, deve ser o semiaberto. 4. Tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal. 5. Ordem concedida tão somente para remover o óbice constante do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, o qual determina que “[a] pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado”. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado. (HC 111840, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 16-12-2013 PUBLIC 17-12-2013)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no ARE 1052700, com REPERCUSSÃO GERAL, julgado em 02/11/2017, considerando inconstitucional a fixação ex lege do regime inicial fechado com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. 2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido. (ARE 1052700 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 02/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

Assim, tendo em vista a quantidade de pena aplicada (mais de 7 anos), reincidência e uma circunstância judicial desfavorável, entendo que o regime mais consentâneo é FECHADO, para o início do cumprimento da pena, tudo na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Destaco que deixo de aplicar a detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a matéria é afeta ao Juízo da Execução, posto que ausente requisito subjetivo nos autos para tanto.

Descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, já que a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos, nos termos dos arts. 44, I, c.c 77, caput e § 2º, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR JULIO CESAR CALADO DO NASCIMENTO, por ter praticado fato tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, às penas de 7 (SETE) ANOS, 3 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 729 (SETECENTOS E VINTE E NOVE) DIAS-MULTA, em regime inicial FECHADO.

Considerando que o réu respondeu ao processo preso, e que a quantidade de drogas que guardava para o fornecimento a terceiros demonstra destemor perante os órgãos de segurança pública, aliado à reincidência e maus antecedentes, entendo que a colocação em liberdade representa risco à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva.

Desta feita, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA, DENEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Condeno o sentenciado também ao pagamento das custas e despesas processuais.

Entretanto, considerando que o sentenciado foi assistido pela Defensoria Pública,

associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Havendo recurso de qualquer das partes, independentemente de nova conclusão, expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo competente para adequação das condições da prisão.

Anote-se a publicação da presente sentença como termo inicial para eventual nova reapreciação da necessidade da prisão preventiva, devendo os presentes autos virem conclusos ao Magistrado com competência funcional sobre o processo (Juiz de Direito ou Desembargador Relator, a depender da fase em que se encontrar) no 85º dia a partir desta data, na forma do Comunicado n. 78/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Após o trânsito em julgado:

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06;

Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral; Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;

Ofícios de praxe;

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Santo André, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA